Processo nº **0090299-25.2019.8.17.2001**

ESPÓLIO: MARIA JOSE GADELHA

ESPÓLIO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Maria José Gadêlha ajuizou ação em face de **Hapvida Assistência Médica Ltda**, buscando, por meio do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, fosse a demandada compelida a fornecer o medicamento Crizotinibe 250mg, conforme prescrição médica.

Afirma, em síntese, que:

a) é beneficiária de contrato de assistência à saúde firmado com a operadora ré;

b) foi diagnosticada como portadora de Adenocarcinoma – CID C34 – Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, em face do que o seu médico assistente indicou, em caráter de urgência, o uso do medicamento Crizotinibe;

c) o tratamento com o fármaco prescrito pelo médico assistente permite uma taxa de controle da doença em torno de 70%, ao passo que o tratamento com a quimioterapia convencional apresenta uma taxa de controle de cerca de 30%;

d) malgrado o tratamento medicamentoso seja imprescindível para a estabilização da doença e o fármaco Crizotinibe tenha sido incorporado ao rol de procedimentos da ANS, a demandada não autorizou a sua cobertura, com fundamento na inexistência de contemplação em diretriz de utilização nº 64 da ANS.

Requereu os benefícios da justiça gratuita, a prioridade no trâmite do feito por ser idosa e portadora de doença grave e, após a apreciação do pedido de tutela antecipada, a abertura de prazo para aditamento da inicial nos termos do disposto no art.303, §1º, I, do CPC/2015.

Juntou documentos.

O Juízo, por meio da decisão de ID 56024395: a) acolheu o pedido de tutela provisória de urgência; b) determinou a intimação da parte autora para: b.1) cumprir o disposto no art.303, §1º, I, do CPC/2015 e b.2) juntar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do requerimento de gratuidade judiciária.

A Hapvida Assistência Médica Ltda apresentou pedido de reconsideração da decisão antecipatória (ID 56865223), noticiou a interposição de agravo de instrumento (ID 57982287). Apresentou contestação (ID 57700001), alegando, em suma, que:

a)a terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer consta do rol de procedimentos e eventos da ANS e é, portanto, de cobertura obrigatória para as operadoras de planos de saúde, desde que respeitados os critérios médicos especificados nas diretrizes de utilização;

b)nos termos da Diretriz de Utilização 64, a cobertura do medicamento Crizotinibe pela operadora de plano de saúde apenas se torna obrigatória no caso de "tratamento de Câncer de Pulmão não pequenas-células, cuja indicação deve ser precedida da confirmação da presença de CPNPC avançado que seja POSITIVO para quinase de linfoma anaplásico (ALK)"

c)conforme relatório médico apresentado pela autora, a detecção do CPNPC foi negativa para ALK, não sendo o tratamento solicitado, portanto, de cobertura obrigatória;

d)outrossim, tratando-se de paciente com gene ALK negativo, inexistem benefícios comprovados com o uso do Crizotinibe.

A parte autora, dando cumprimento à determinação do Juízo, aditou a petição inicial. Na oportunidade, informou o descumprimento da decisão antecipatória, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de multa cominatória e ao pagamento de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) referente ao gasto com o tratamento medicamentoso deferido nos autos (ID 57733270).

Ao tempo em que o Juízo indeferiu o pedido de reconsideração da decisão antecipatória, afastou a aplicação da multa cominatória anteriormente fixada e determinou que a ré promovesse o ressarcimento à autora do valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) em cumprimento à decisão de tutela provisória de urgência. Na oportunidade, determinou a intimação da demandante para prestar esclarecimentos acerca do modo de realização do tratamento, indicar conta bancária para ressarcimento e recolher as custas processuais, posto que indeferiu o requerimento de gratuidade judiciária (ID 59348851).

Noticiado o óbito da autora (ID 66543792), foi determinada a suspensão do processo e a intimação dos herdeiros/espólio para fins de habilitação nos autos (ID 66718180).

O Juízo promoveu a correção do valor atribuído à causa de ofício (ID 73844761).

A parte ré, citada (ID 79257041), não apresentou óbice ao pedido de habilitação do espólio formulado por meio da petição de ID 76673785.

É o que importa relatar. Decido.

Ante a regularidade da documentação apresentada pelo Espólio de Maria José Gadelha e em face da ausência de apresentação de impugnação pela ré, defiro o pedido de habilitação apresentado nos autos com fulcro no art.691 do CPC/2015.

Proceda-se à habilitação do Espólio de Maria José Gadelha, representado pelo inventariante Carlos Gadelha Junior (Termo de Abertura de Inventário Extrajudicial - ID 76673786), alterando-se o polo ativo deste feito.

Defiro ainda o requerimento de gratuidade judiciária contido em petição de ID 76673785.

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do disposto no art.355, I, do CPC/2015, porquanto desnecessária a produção de outras provas.

Infere-se do laudo médico (ID 56008131) que a falecida Maria José Gadêlha foi acometida por neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, sendo imprescindível o tratamento medicamentoso com o fármaco Crizotinibe (1 comprimido via oral 12/12h – uso contínuo até progressão da doença ou toxicidade limitante) prescrito pelo médico assistente, sob pena de agravamento do estágio clínico da paciente e morte.

Extrai-se dos autos que a ré negou cobertura ao tratamento por não se enquadrar nas Diretrizes de Utilização estabelecidas pela ANS (DUT n°64) – ID 56008183.

O contrato firmado entre as partes encerra relação de consumo, desafiando a aplicação da legislação consumerista, nos exatos termos do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).

Além disso, ao caso também deve ser aplicada a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

O art. 10 da referida lei preceitua que, *in verbis*:

> ***Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde,*** *com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar,* **das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e**

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, *respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

§1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.

*§***2o As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.**

§3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o §2o deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos.

§4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o plano-referência, que deverá ser obrigatoriamente oferecido por toda e qualquer operadora de contrato de assistência à saúde, deve necessariamente assegurar cobertura a todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, ressalvadas as exclusões enumeradas nos incisos I a X.

No presente caso, segundo laudo médico juntado aos autos, a falecida era portadora de doença que consta da lista da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da

Organização Mundial de Saúde, a saber neoplasia maligna do brônquio principal (CID 10 C34[i]), e que, portanto, possuía cobertura pelo contrato de assistência à saúde do qual era beneficiária.

Demais disso, o tratamento solicitado pelo médico assistente não está previsto no rol de exclusões constante dos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/98. Pelo contrário, há expressa previsão de que o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar terá cobertura obrigatória quando configuradas as hipóteses previstas no art.12, I, "c" e II, "g", da Lei 9.656/98, que dizem respeito aos tratamentos antineoplásicos.

Vejamos:

> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *(...)*
>
> ***c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;***
>
> *(...)*
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *(...)*
>
> ***g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;***

A despeito da previsão inserta no art.12, §4°, da Lei 9.656/98 ("*As coberturas a que se referem as alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II deste artigo serão objeto de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, revisados periodicamente, ouvidas as sociedades médicas de especialistas da área, publicados pela ANS")* e da ausência de previsão da medicação Crizotinibe para todo e qualquer caso de neoplasia no pulmão na DUT n°64 da ANS[ii], tenho que **a operadora demandada não pode se recusar a custear determinado tratamento/procedimento única e exclusivamente sob a alegação de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, quando imprescindível para o tratamento da beneficiária**, segundo o médico assistente, como ocorreu *in casu*, **considerando a declaração médica de progressão da doença e risco de morte.**

Cumpre mencionar que a Terceira Turma do STJ permanece tomando por exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Nesse sentido, confira-se:

> *AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.*
> *AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ.*
> *1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde.*
> *2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.*
> *3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais.*
> *4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ.*
> *5. Agravo interno não provido.*
> *(AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03*

Destaque-se, por oportuno, que ainda que se conclua que rol de procedimentos e eventos em saúde emanado da ANS não é meramente exemplificativo, nos termos do REsp 1733013/PR, tal julgado ressalvou a cobertura de tratamento efetivamente imprescindível para a saúde do beneficiário, ainda que não previsto no rol de procedimentos.

Não há dúvida de que, in *casu*, o tratamento médico em questão era imprescindível à saúde da paciente.

Pontue-se ainda que o medicamento prescrito à autora está regularizado e registrado perante a ANVISA e que consta de sua bula/manual[iii] a indicação para o tratamento de câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) avançado que seja positivo para ROS1, que é exatamente o caso da autora (laudo médico ID 56008131).

Outrossim, resta pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente, não estando a seguradora habilitada, nem tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor. Isso porque a seguradora não pode substituir-se aos médicos na opção terapêutica. Assim, se a patologia está prevista no contrato, não

pode haver qualquer mitigação quanto ao procedimento recomendado pelo médico quando da avaliação do paciente e de sua patologia, por quem não detém técnica nem competência para fazê-lo.

Confira-se:

> *"A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n ° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde. De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato. Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente. Além de representar severo risco para a vida do consumidor. Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n ° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n ° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02). Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a utilização de esfíncter artificial para controle da micção. O mesmo se diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a cura da doença. Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor" (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 29/06/2007).*

Nesse contexto, ao tempo reconheço a ilegalidade da recusa da ré em custear o tratamento medicamentoso solicitado pelo médico assistente da falecida autora, confirmando os efeitos da decisão concessiva da tutela provisória de urgência, reconheço o dever de o ressarcimento do valor indicado em nota fiscal de ID 57733272, qual seja R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), gasto pela falecida para realização de seu tratamento em face da desídia da ré em custeá-lo.

A pretensão de reparação civil por danos morais também merece acolhida.

Malgrado, em regra de princípio, o mero inadimplemento contratual seja insuficiente à configuração de danos extrapatrimoniais, a jurisprudência vem reconhecendo que a indevida recusa a cobertura de contrato de assistência à saúde pode sim ensejar a configuração de dano moral indenizável (STJ: AREsp 946150/SP; AREsp 919439/RJ; AREsp 708894/DF; AgInt no AREsp 1022746/RN; AgRg no AREsp 666568/RJ).

É que, se de um lado é certo que, no mais das vezes, o não cumprimento de obrigação contratual impõe prejuízos de ordem unicamente material, de outro, importa ver que, em determinadas circunstâncias, o descumprimento do contrato pode exacerbar a seara patrimonial, dando causa a uma violação dos direitos da personalidade, ao comprometimento da honra, da dignidade ou da intimidade da pessoa humana, ou mesmo deflagrando ou agravando séria e compreensível situação de angústia, insegurança, aflição ou dor psíquica e/ou física de quem já se acha com a saúde debilitada. Nessas situações, do descumprimento do contrato decorrerá não só danos materiais, mas também morais, e, dado que a Constituição da República adotou o princípio da reparação integral (art. 5º, V e X), além de responder pelas perdas e danos materiais (art. 389 do CC), o responsável pelo inadimplemento deverá indenizar também os danos extrapatrimoniais.

Certamente, a recusa na autorização do tratamento médico solicitado pela falecida autora e prescrito pelo seu médico assistente, **em razão do diagnóstico de neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões, com risco de morte, foi suficiente para agravar a angústia, a insegurança, a aflição e a dor psíquica da qual inexoravelmente já se achava acometida a paciente.**

Em verdade, não há como deixar de reconhecer que a falecida autora, **já extremamente desgastada física e emocionalmente, viu-se inesperadamente desamparada justamente por aquele que foi contratado e remunerado para ampará-la nessa circunstância.**

Ora, quem se vincula a contrato de assistência à saúde o faz em busca de segurança e confiança futura para os seus bens mais preciosos: a saúde e a vida. Assim, o descumprimento de contrato dessa natureza, ao frustrar tais expectativas, impingindo ao paciente a sensação de abandono, à toda evidência é capaz de causar-lhe profunda dor psíquica e sofrimento indenizável a título de dano moral.

À vista de tais considerações, tenho como configurados o dano moral e o dever de indenizar.

Destaque-se que muito embora os danos morais atinjam apenas os direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização, por sua vez, é patrimônio passível de ser transmitido aos herdeiros com o falecimento do titular do direito.

Neste sentido, o que se transmite aos herdeiros não é o aspecto subjetivo da violação, mas seu aspecto patrimonial-indenizatório. Neste teor, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

> *AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 954.897 – MG (2016/0191184-0) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE : CONDOMÍNIO DO EDFICIO PALAIS DE LUXEMBURGO ADVOGADOS : RÔMULO DE GOUVÊIA E OUTRO (S) – MG040760 BARBARA EMANUELLE ROCHA GUIMARAES NOGUEIRA – MG137147 GIUSEPPE ANGELI NETO – MG160819 AGRAVADO : JOAQUIM ROQUE TEIXEIRA – ESPÓLIO REPR. POR : CLAUDIO HENRIQUE DE REGINI TEIXEIRA – INVENTARIANTE ADVOGADO : ÉRICO XAVIER LIMA – MG088364 DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ e por falha na indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como por falta de demonstração do dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 308/310). Em suas razões (e-STJ fls. 314/334) o agravante alega ter procedido ao cotejo analítico e à indicação do dispositivo legal que teve interpretação divergente, além de ter evidenciado a divergência de entendimentos entre o TJMG e o STJ. Assim, com base no art. 259, § 6º, do RISTJ, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do agravo nos próprios autos, interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial sob o fundamento de aplicação da Súmula n. 83 do STJ e de falha no cotejo analítico dos acórdãos recorrido e paradigma (e-STJ fls. 278/279). O acórdão do TJMG traz a seguinte ementa (e-STJ fl. 227): APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – MATÉRIA ESTRANHA AO CONDOMÍNIO – REJEIÇÃO FALECIMENTO AUTOR – DIREITO PERSONALÍSSIMO – REJEIÇÃO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EMISSÃO DE LETRA DE CÂMBIO E PROTESTO – ATO ILÍCITO – A cláusula estabelecida na convenção de condomínio de convenção de arbitragem se aplica apenas as questões referentes aos débitos e relação entre condôminos, não atingindo ações de indenização por danos morais. – Quando já ajuizada a ação por danos morais, o falecimento do autor possibilita a habilitação do cônjuge sobrevivente ou herdeiro, uma vez que o direito personalíssimo se transforma em direito patrimonial. – O saque de letra de cambio contra quem não é proprietário do imóvel no condomínio e seu respectivo protesto sem aceite, constitui ato ilícito, sujeito a indenização por danos morais. No recurso especial (e-STJ fls. 249/255), com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, o recorrente apontou ofensa ao disposto no art. 11 do CC/2002, sustentando, em síntese, que o espólio é parte ilegítima para pleitear ressarcimento por danos morais sofridos pelo de cujus, sendo inadmissível destinar ao*

espólio o dano moral. Ofereceram-se contrarrazões (e-STJ fls. 272/276). No agravo (e-STJ fls. 282/288), foram refutados os fundamentos da decisão agravada e alegado o cumprimento de todos requisitos legais para recebimento do especial. Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 291/297). É o relatório. Decido. (...) A mesma posição já foi manifestada pelo STJ: PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE. ACIDENTE. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA PROLATADA. DESNECESSIDADE. TRANSMISSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE. MORTE DO CÔNJUGE DO QUAL A AUTORA ERA SEPARADA DE FATO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. I. ***A morte da autora, no curso do processo, com a instrução finda, não obsta a prolação da sentença. II. A ação por danos morais transmite-se aos herdeiros dos autos, por se tratar de objeto patrimonial.*** *III. Culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade da empresa pelo evento danoso, podendo, apenas, diminuir o quantum da indenização. IV. Justifica-se a indenização por danos morais quando há presunção, em face de estreita vinculação existente entre a postulante e a vítima, de que o desaparecimento do ente querido tenha causado reflexos na assistência doméstica e significativos efeitos psicológicos e emocionais em detrimento da autora, a ser privada para sempre da companhia do de cujus. V. Tal suposição não acontece em relação ao cônjuge que era separado de fato do de cujus, habitava em endereço distinto, levando a acreditar que tanto um como outro buscavam a reconstituição de suas vidas individualmente, desfeitos os laços afetivos que antes os uniram. VI. Recurso especial conhecido em parte, e nessa parte, parcialmente provido. Dano moral indevido, pelas peculiaridades da espécie (STJ - REsp 647562 MG - Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior). (...) Assim, a par da divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, peço vênia aos que entendem de forma diversa, mas adoto a segunda tese, ou seja, da transmissão condicionada, o que ocorre nos autos. No mesmo sentido, outrossim, rejeito a preliminar. É firme, ainda, a jurisprudência do STJ de ser transmissível ao espólio o direito ao ajuizamento da ação indenizatória, no caso de falecimento do titular. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. FALECIMENTO DO TITULAR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. SÚMULA N.º 168/STJ.* ***A posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido de embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus.*** *Incidência da Súmula n.º 168/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp n. 978.651/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/12/2010, DJe 10/2/2011.) Incide a Súmula n. 83 do STJ. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator(STJ - AgInt no AREsp: 954897 MG 2016/0191184-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/06/2018)*

Fixo o valor da indenização.

A indenização em face do dano moral tem caráter reparatório e punitivo-pedagógico. De um lado, objetiva reparar, ainda que de forma paliativa, a angústia experimentada pelo lesado. De outro, visa motivar o ofensor a adotar novas práticas, cercando-se de novos cuidados, a fim de não mais incidir em condutas ilícitas da mesma natureza, vale dizer, tenciona impedir a repetição de fatos idênticos ou assemelhados.

De realçar ainda a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na fixação do *quantum* indenizatório de dano moral "[...] recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (REsps. nºs. 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP).

No caso dos autos, tenho que a demandada agiu com **culpa grave**, pois quando da desídia em autorizar o tratamento da falecida, **tinha ciência de seu grave estado de saúde**. Inarredável a conclusão de que o descumprimento contratual foi voluntário e consciente, agindo a ré com culpa grave.

Por outro lado, a demandada é empresa de significativo porte financeiro. **Indenização modesta em termos pecuniários certamente não a estimulará a revisar conceitos e comportamentos com o objetivo de não mais praticar a conduta ilícita. Ademais, indenizações módicas têm permitido que os fornecedores em geral lucrem com a ofensa moral, preferindo, aqui e ali, arcarem com indenizações a aparelharem-se adequadamente segundo as exigências do mercado consumidor e as interpretações assentadas pelo Poder Judiciário.**

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando sobretudo as peculiaridades do caso, já bem delineadas, para garantir à parte autora a justa reparação pelos danos sofridos, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ainda atenta ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda, fixo a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

À vista do exposto, extinguindo o processo com resolução de mérito, julgo procedentes os pedidos (art. 487, I do CPC/2015) e, confirmando os efeitos da decisão antecipatória, condeno a demandada **Hapvida Assistência Médica Ltda** a:

1.ressarcir à parte autora o valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) despendido com a compra do medicamento Crizotinibe, acrescido de correção monetária (índices da tabela do Encoge) e juros legais de mora (1% ao

mês), a partir do efetivo desembolso (20.01.2020 - data da compra da medicação – ID 57733272);

2. pagar à parte demandante, a título de indenização por danos morais, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária (índices da tabela do Encoge), a partir do presente arbitramento (súmula 362 do STJ), e de juros legais de mora (1% - um por cento ao mês - art. 406 do CC c/c art. 161, §1°, do CTN), a partir da data da citação (art. 405 do CC);

3. pagar ao(s) advogado(s) constituído(s) pela parte autora honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2°, do CPC/2015;

4. pagar a totalidade das custas e despesas processuais, que devem ser recolhidas diretamente aos cofres públicos, posto que não chegaram a ser adiantadas pela parte autora, à qual foram concedidos, neste ato, os benefícios da gratuidade da justiça.

Deve a parte demandada, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, comprovar nos autos o pagamento das custas processuais que lhe é cabível. **Disponibilidade a Diretoria Cível a guia de pagamento de custas, observando a correção ao valor atribuído à causa disposta em decisão de ID 73844761.**

Decorrido o prazo sem pagamento, oficie-se à Fazenda Estadual, dando-lhe ciência da existência do crédito em favor do Estado de Pernambuco. Oficie-se, ainda, à Presidência do Tribunal, em atenção ao Provimento n°007/2019, do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em caso de enquadramento do devedor nas hipóteses previstas em seu art.1°.

Proceda-se à habilitação do Espólio de Maria José Gadelha, representado pelo inventariante Carlos Gadelha Junior

Promova a Diretoria Cível de 1° Grau a correção do assunto atribuído ao presente feito, alterando-o para "Fornecimento de Medicamentos (12487)".

Opostos embargos de declaração com efeito modificativo, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. (art. 1.023, § 2°, do CPC/2015), e decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, determino a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões (art. 1010, §1°, do CPC/2015). Havendo alegação – em sede de contrarrazões - de questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportaram agravo de instrumento, intime-se a parte adversa (recorrente) para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. 1.009, §§ 1° e 2°, do CPC/2015). Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se a parte apelante para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010,

§2°, do CPC/2015). Em seguida, com ou sem resposta, sigam os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com os cumprimentos deste Juízo (art. 1010, §3°, do CPC/2015).

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, independentemente de nova determinação.

Intimem-se.

Recife-PE, data da assinatura digital.
Mariana Vargas Cunha de Oliveira Lima
Juíza de Direito

---

[i] https://cid10.com.br/%5Ebuscacode$?query=C340

[ii]http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn465/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_TEA.AL.pdf

[iii] https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351725846201208/

Assinado eletronicamente por: MARIANA VARGAS CUNHA DE OLIVEIRA LIMA
14/06/2021 21:29:05
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 82173210

21061421290526700000080463454

IMPRIMIR GERAR PDF